



ANALISTA DOS TRIBUNAIS
BRUNO BETTI
DIREITO ADMINISTRATIVO
AULA 12

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: Contratos Administrativos

- 6) Cláusulas Exorbitantes – art. 104
- 7) Elaboração de Termo ou Instrumento Contratual
- 8) Publicação do extrato do contrato
- 9) Áleas
- 10) Extinção dos Contratos
- 11) Nulidade dos contratos – art. 147 a 150
- 12) Meios alternativos de resolução de controvérsias – art. 151 a 154

6) Cláusulas Exorbitantes – art. 104

6.1) Conceito

- Cláusulas abusivas e ilícitas no âmbito do direito privado, mas legitimadas no âmbito público
- Decorrem da Lei no caso dos contratos de direito público
- Para os contratos de direito privado precisam de previsão expressa no contrato

6.2) Espécies

6.2.1) Modificação unilateral

- Estudadas a seguir

6.2.2) Extinção unilateral

- Estudada a seguir

6.2.3) Fiscalização do Contrato

- Da execução do contrato
- Art. 115 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- É proibido à Administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante.
- Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- Nas contratações de obras, caso haja impedimento, paralisação ou suspensão do contrato por mais de 1 mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável da inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução.
- Das obrigações do contratado na execução do contrato
- Art. 119 - O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

- Art. 120 - O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.
- Das obrigações do contratado na execução do contrato
- Art. 121 - **Somente** o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis.
- **Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado.**
- Das obrigações do contratado na execução do contrato
- Nesses contratos, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a Administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas:
 - I. exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas;
 - II. condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato;
 - III. efetuar o depósito de valores – que são absolutamente impenhoráveis – em conta vinculada;
 - IV. em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado;
 - V. estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador.
- STF:
 1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.

2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.

3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.

4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá:

(i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e

(ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

- Sobre o julgado:

Cabe ao autor da ação — para fins de definição da responsabilidade subsidiária da Administração Pública — o ônus da prova sobre eventual conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada.

A responsabilização subsidiária do poder público não é automática, pois depende da comprovação de culpa *in eligendo* ou *in vigilando*, que decorre da obrigação da Administração Pública de fiscalizar os contratos administrativos que são presumidamente válidos, legais e legítimos e, consequentemente, somente podem ser contestados se houver idônea comprovação de irregularidade (1).

Nesse contexto, é de quem aciona o Poder Judiciário o ônus de comprovar a efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público na fiscalização dos contratos.

Dever de fiscalização e suas consequências

O voto reconhece que:

- A Administração tem **dever legal de fiscalizar** (cf. art. 58, III, da Lei nº 8.666/93 e IN nº 2/2008).
- No entanto, **a omissão na fiscalização só gera responsabilidade se comprovada**.

O comportamento negligente estará comprovado quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal e fundamentada de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas.

A negligência, para gerar responsabilidade, **depende de notificação formal** de inadimplemento (por sindicatos, MPT, Defensoria, etc.) e **inércia do poder público**.

Na espécie, o Estado de São Paulo questionou decisão do Tribunal Superior do Trabalho que o responsabilizou, de forma subsidiária, por parcelas devidas a um trabalhador contratado por empresa prestadora de serviço, tendo

em vista que os documentos apresentados pelo referido ente federativo não seriam suficientes para demonstrar a efetiva fiscalização relativa ao pagamento das obrigações trabalhistas.

- Das obrigações do contratado na execução do contrato

Art. 116 - Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado, sob pena de rescisão do contrato (art. 137, IX) deverá cumprir a reserva de cargos para:

- 1) pessoa com deficiência,
- 2) para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz
- 3) as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

Sempre que solicitado pela Administração, o contratado deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas.

Bloco 2

6.2.4) Aplicação de Sanção

Fruto do Poder Disciplinar (NÃO do poder de polícia)

- I. Advertência;
- II. Multa;
- III. Impedimento de licitar e contratar;
- IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

- Obs. não há ordem para aplicação
- Obs.2 a lei 14.133 reduziu a discricionariedade do administrador, se comparada com a lei 8.666. Esta última era muito vaga, sendo que a primeira trouxe melhores parâmetros para a discricionariedade.

6.2.4.1) Advertência

Art. 156, §2º - Será aplicada **exclusivamente** no caso de **inexecução parcial** do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade considerada mais grave.

Obs. note que a advertência é exclusiva da inexecução

Obs.2. a inexecução do contrato pode gerar outras sanções

6.2.4.2) Multa

Art. 156, §3º - Não poderá ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas.

Art. 156, §7º - A multa pode ser aplicada isolada ou cumulativamente

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

Por fim, atente-se que, caso aplicada a multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

6.2.4.3) Impedimento de licitar e contratar

Será aplicada nas seguintes infrações administrativas:

- 1) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 2) dar causa à inexecução total do contrato;
- 3) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 4) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 5) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 6) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

Atente-se ao fato de que o impedimento será aplicado nas infrações acima, caso não se justifique a imposição da penalidade de declaração de inidoneidade.

obs. impedimento é uma conduta grave e atentatória contra aquela licitação ou contrato. Diferencia da declaração de inidoneidade, que é atentatória contra o instituto da licitação/contrato (essência)

ATENÇÃO!!!!

Impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do **ente federativo que tiver aplicado a sanção**, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

6.2.4.4) Declaração de Inidoneidade

A declaração de inidoneidade será aplicada nas seguintes infrações administrativas:

- 1) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- 2) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 3) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 4) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 5) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013, a Lei Anticorrupção.

Também será aplicada a declaração de inidoneidade nas infrações disciplinares para ensejar o impedimento de contratar, quando justificar a imposição de penalidade mais grave.

ATENÇÃO!!!

Atente-se que a penalidade ora estudada impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta **de todos os entes federativos**, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

A declaração de inidoneidade será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

- I. quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal;
- II. quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;
- III. quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente aos Ministros e Secretários de Estado.

A aplicação da declaração de inidoneidade só abarca as relações jurídicas futuras, razão pela qual produz efeitos *ex nunc*.

Processo de Responsabilização

Caso as sanções aplicadas sejam o impedimento ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, será necessária a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, **preferencialmente** com, **no mínimo**, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade.

Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

- I. interrompida pela instauração do processo de responsabilização;
- II. suspensão pela celebração de acordo de leniência, nos termos da Lei nº 12.846/13;
- III. suspensão por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

Apuração conjunta

Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/21 ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/13 (responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira)

serão **apurados e julgados conjuntamente**, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

Desconsideração da personalidade jurídica – art. 160

A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei ou para provocar confusão patrimonial.

Adoção pela teoria maior

Reabilitação

Será admitida, nos termos do art. 163 da Lei nº 14.133/21, a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, **cumulativamente**:

- I. reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- II. pagamento da multa;
- III. transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- IV. cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- V. análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos acima.

Quando a sanção decorrer das infrações de apresentação de declaração ou de documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato, bem como da prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013, a Lei Anticorrupção, exigirá a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

Atenção no inciso III:

- impedimento de licitar – transcurso mínimo de 1 ano;
- declaração de inidoneidade – transcurso de prazo mínimo de 3 anos

Bloco 3

6.2.5) Ocupação provisória

A Administração Pública poderá ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, nas hipóteses de:

- a) risco à prestação de serviços essenciais;
- b) necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato.

6.2.6) Aplicação **diferida** da Exceção do contrato não cumprido – art. 137, §2º

Trata-se da premissa de que: quem não cumprir sua parte do contrato não pode exigir que a outra cumpra a sua respectiva

O contratado terá direito à extinção do contrato, além de outras situações, nas seguintes hipóteses:

- 1) suspensão de execução do contrato, **por ordem escrita da Administração**, por prazo superior a 3 (três) meses;
- 2) repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;
- 3) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos.

Nesses casos, especificamente:

- 1) não serão admitidas a extinção em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;
- 2) assegurarão ao contratado o **direito de optar pela suspensão** do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

7) Elaboração de Termo ou Instrumento Contratual

Será **obrigatório** como regra, nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133/21.

Por outro lado, será **facultativo** nas seguintes hipóteses:

- 1) dispensa de licitação em razão de valor;
 - 2) compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.
- Nesses casos, a Administração poderá substituir o instrumento de contrato por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

8) Publicação do extrato do contrato

Art. 94 - É preciso divulgar o contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), como condição indispensável para a sua **eficácia** e dos seus aditamentos, devendo ocorrer nos seguintes prazos, **contados da data de sua assinatura**:

- 1) 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;
- 2) 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.

Fato relevante refere-se aos contratos celebrados em caso de urgência. Esses contratos terão eficácia a partir da sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos acima, sob pena de nulidade.

Os Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

9) Áleas

- Os riscos de celebrar contrato com a Administração

Reajuste	Revisão	Repactuação
Consiste na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção , admitida a adoção de índices específicos ou setoriais	Decorrente de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato	Utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra , por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas , para os custos decorrentes do mercado , e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra .
Prazo mínimo de 1 ano	Independente de prazo	Prazo mínimo de 1 ano
Quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais		Quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.
Cláusula Necessária		Cláusula Necessária
Simples Apostila – Dispensado Termo Aditivo	Termo Aditivo	Simples Apostila – Dispensado Termo Aditivo

[LEI Nº 10.192, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001. Conversão da MPv nº 2.074-73, de 2001](#) Dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências.

9.1) Álea Ordinária

- Risco ordinário de todo negócio
- Suportada pelo contratado
- Ex. STJ diz que a inflamação é uma espécie

9.2) Álea Extraordinária

- pode ser administrativa ou econômica, sendo a primeira a mais relevante para o estudo

9.2.1) Administrativa

9.2.1.1) Alteração Unilateral

- Recaem sobre as Cláusulas Regulamentares ou de execução – Estabelecem a forma de execução do contrato
- Não podem recair sobre as Cláusulas econômico-financeiras e monetárias
- As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.
- De outro lado, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.
- Observe que as alterações unilaterais devem recair sobre as cláusulas regulamentares ou de execução. Estas são aquelas cláusulas que vão estabelecer a forma de execução dos contratos. Ex.: a parede deve ser pintada de azul. A Administração decide modificar unilateralmente e estabelece que vai ser colocado mármore na parede.
- Por sua vez, as cláusulas financeiras ou econômico-financeiras estão relacionadas aos aspectos financeiros dos contratos, como, por exemplo, o preço.
- art. 126 dispõe que as alterações unilaterais não poderão transfigurar o objeto da contratação, assim deve-se preservar a identidade do objeto contratado.
- Alterações qualitativas e quantitativas
 - Qualitativas: para melhor especificação do objeto
 - Quantitativa: altera apenas a quantidade para mais ou menos
 - Para ambas haverá a limitação de valor – Expresso na nova lei
 - o contratado fica obrigado a aceitar:
 - a) nos contratos de compras, obras e serviços: acréscimos e supressões de até 25% do valor
 - b) reforma de edifício ou equipamento: acréscimos de até 50% do valor de contrato
 - Obrigatório o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato após alterações
- Art. 130 – Alteração unilateral que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
- Art. 131 - A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.
- Art. 131, § único - O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação.
- Art. 132 - A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 mês

Bloco 4

- Art. 129 - Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
- Art. 136 - Os registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
 - I. variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato;
 - II. atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;
 - III. alterações na razão ou na denominação social do contratado;
 - IV. empenho de dotações orçamentárias.

9.2.1.2) Alteração bilateral – art. 124, II

- Acordo entre as partes

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

Obs. Contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado.

9.2.2) Fato do Príncipe

- Medidas de autoridade pública, de caráter geral, que não incidem diretamente do contrato, mas repercutem neste
- Recai sobre toda a sociedade

- Positivo: onerar o contrato
- Negativo: desonerar o contrato
- Ex. Alteração de alíquotas de impostos por ente diferente – Teoria da imprevisão para parte da doutrina.
- Enseja reequilíbrio

9.2.3) Fato da Administração

- Medida da administração que recai diretamente no contrato
- Ex. descumprimento contratual por parte da Adm.
- Pode ensejar reequilíbrio ou extinção do contrato conforme o caso concreto

9.3) Álea Econômica

- Teoria da imprevisão
- Fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis – ex. guerra, pandemia
- Enseja a revisão do contrato

10) Extinção dos Contratos

10.1) Extinção unilateral

Ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta.

A extinção unilateral deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

De acordo com art. 139 da Lei nº 14.133/21, essa extinção, como ocorrerá sem culpa da Administração, poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei, as seguintes consequências:

- I. assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;
- II. ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade.
 - As medidas ficarão a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.
 - No caso específico da ocupação e utilização de local, instalações e demais, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado, do secretário estadual ou do secretário municipal competente

III. execução da garantia contratual, para:

- a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;
- b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;
- c) pagamento de valores das multas devidas à Administração Pública;
- d) exigência da assunção da execução e conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

IV. retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

Direitos do contratado:

Art. 138, §2º - Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I – devolução da garantia;

II – pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da extinção; e

III – pagamento do custo da desmobilização.

10.2. Extinção Consensual

Nos termos do art. 138, II, a extinção consensual ocorrerá por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração.

10.3. Extinção Determinada por Decisão Arbitral ou Decisão Judicial

Trata-se de extinção que ocorrerá nas situações em que não houver um acordo entre Administração e contratado, de modo que a extinção contratual será determinada em decisão arbitral ou em decisão judicial, conforme o caso.

11) Nulidade dos contratos – art. 147 a 150

Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, **caso não seja possível o saneamento**, a decisão sobre a suspensão da execução ou anulação do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos:

- I. impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;
- II. riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;
- III. motivação social e ambiental do contrato;
- IV. custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas;
- V. despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados;
- VI. despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;

- VII. medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados;
- VIII. custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas;
- IX. fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação;
- X. custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato;
- XI. custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação.

A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia do interesse público envolvido, e **operará retroativamente**, impedindo os efeitos jurídicos que deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos.

– regra: ex tunc

Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será resolvida pela **indenização por perdas e danos**, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. – ex nunc

Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha eficácia **em momento futuro**, suficiente para efetuar nova contratação, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogável uma única vez. – Prospectivo/ pró futuro

Art. 149 - a nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa.

Bloco 5

12) Meios alternativos de resolução de controvérsias – art. 151 a 154

Conciliação, Mediação, Comitê de resolução de disputas e a Arbitragem

Serão aplicados às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao cálculo de indenizações.

Enunciado 19, da I Jornada de Direito Administrativo (mesmo sentido)

Para contratos que originalmente não estabeleçam os meios alternativos de solução de conflitos, o art. 153 permite sejam adotados para que haja a adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsia.

Enunciado 10, da I Jornada de Direito Administrativo

12.1) Arbitragem

Art. 1º, §1º, da Lei da Arbitragem (Lei nº 9.307/96), a Administração Pública direta e indireta – arbitrabilidade subjetiva – poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

A autoridade ou o órgão competente da Administração Pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações.

Perceba-se ainda que as questões que podem ser submetidas à arbitragem referem-se às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis – arbitrabilidade objetiva.

Art. 152 da Lei nº 14.133/21 - A arbitragem será sempre de direito – vedada a arbitragem por equidade – e observará o princípio da publicidade.

A mesma disposição está prevista no art. 2º, §3º da Lei de Arbitragem.

Cláusula Compromissória e Compromisso Arbitral

Cláusula Compromissória - É a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

Deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.

Compromisso Arbitral - Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral.

É a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial.

12.2) Comitê de Resolução de Disputas (dispute boards)

O comitê de resolução de disputas ou o dispute board (DB) é um mecanismo alternativo de solução de controvérsias que busca resolver conflitos, especialmente com relação a contratos de longa duração, notadamente os contratos de infraestrutura e de inovação científica e tecnológica.

O DB é formado por um comitê composto por profissionais especialistas e independentes, nomeados para acompanharem a execução contratual, desde o início ou nos momentos mais críticos do projeto, e sugerirem/decidirem soluções às eventuais controvérsias técnicas que possam surgir ao longo da execução contratual.

Quanto à composição - a prática contratual normalmente adota a formação por três membros, cada parte contratante indicando um dos componentes. Os dois indicados, então, nomeiam um terceiro membro.

Dessa forma, o dispute board proporciona uma espécie de gerenciamento que previne o acirramento das divergências e conflitos oriundos do desgaste natural das relações entre as partes envolvidas.

A adoção pelo comitê de resolução de disputas gera vantagens na execução contratual, que podem ser resumidas em (i) fator qualitativo das manifestações; (ii) diminuição da litigiosidade nos contratos; (iii) celeridade na resolução de conflitos; e (iv) integração de contratos incompletos, reduzindo incertezas; (v) redução de custos.

Atente-se que o DB pode ser dividido em três categorias tratadas pela doutrina especializada e visualizadas na prática de seu manejo contratual, quais sejam:

1) a recomendatória,

2) a adjudicatória e

3) a mista

No DB recomendatório, os comitês fazem recomendações, e são chamados de dispute review boards – DRB.

No DB adjudicatório, os comitês irão tomar decisões, e são chamados de dispute adjudication boards – DAB.

o DB misto é aquele que terá ambas as funções, sendo, portanto, chamado de combined dispute boards – CDB.

Por fim, de acordo com art. 154, o processo de escolha dos comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes.

Agora, algumas questões para fixação de conteúdo:

Considere que a empresa Y apresentou ao Ministério Público representação suscitando que contrato celebrado entre o município X e a empresa Z é irregular e, portanto, precisa ser anulado. O contrato tem por objeto a construção de três terminais de ônibus, em que serão realizadas baldeações e interligações entre os mais variados modais de transporte urbano de passageiros. Na denúncia, narra que a empresa vencedora da licitação não possuía, ao tempo da assinatura do contrato, certidões de regularidade fiscal e há fortes suspeitas de superfaturamento na execução da obra. Com base na situação hipotética e na atuação do Ministério Público no controle das contratações públicas, é correto afirmar que

A caso declarada a nulidade do contrato, o Ministério Público não pode concordar que a eficácia desse ato se protraia para o futuro, pelo tempo suficiente para se efetuar uma nova contratação.

B se declarada a nulidade do contrato por culpa concorrente do contratado, estará a Administração exonerada do dever de indenizá-lo pelo que houver executado até a data em que for declarada a invalidação

C para recomendar que o município declare a nulidade do contrato, o Ministério Público deverá avaliar se os vícios não são passíveis de saneamento, bem como, dentre outros aspectos, o custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas e o custo de oportunidade do capital diante do período de paralização.

D caso seja comprovada a irregularidade na fase de licitação e superfaturamento, a execução da obra deve ser, mediante autorização judicial, paralisada, e o contrato, ao final, anulado.

E estará caracterizado o superfaturamento se preço orçado para licitação ou contratado tiver valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, bem como na hipótese de alteração do projeto que gere desequilíbrio econômico-financeiro em favor do contratado.

A sociedade empresária Boa Obra Ltda. foi contratada verbalmente pelo Município de Para Lá do Brejo, sem qualquer processo licitatório, para construir uma escola municipal. O preço ajustado está rigorosamente em conformidade com o mercado, inexistindo qualquer superfaturamento. Ao final da obra, após a aceitação plena do edifício pelos servidores responsáveis pela fiscalização da obra, o município declara a nulidade do contrato e paga à sociedade empresária apenas o valor do material utilizado na obra.

À luz da legislação de regência, a conduta do Município de Para Lá do Brejo é:

A lícita, pois a declaração de nulidade do contrato impõe apenas a indenização pelo material utilizado na obra, sem a obrigação de pagar serviços de terceiros;

B lícita, pois embora a legislação de regência não restrinja a indenização ao material empregado na obra, o dever de cautela impede o pagamento dos demais itens;

C ilícita, pois o contrato nulo não cria direito em favor do contratado, cuja má-fé é presumida, de modo que não cabia ao município pagar sequer o valor do material;

D ilícita, pois a declaração de nulidade do contrato opera retroativamente e deve desconstituir os efeitos já produzidos, podendo a escola, inclusive, ser demolida;

E ilícita, pois a declaração de nulidade do contrato não afasta o direito à indenização por todas as perdas e danos do contratado, sob pena de enriquecimento sem causa.

A respeito da extinção dos contratos administrativos conforme dispõe a Lei n.º 14.133/2021, assinale a opção correta.

A A extinção do contrato administrativo pode ser determinada unilateralmente pela administração pública, ainda que o descumprimento contratual tenha decorrido de conduta da própria administração.

B A utilização das instalações e dos equipamentos necessários à continuidade do contrato deverá ser imediata, independentemente de autorização do gestor público competente, em caso de extinção do contrato administrativo por ato unilateral da administração pública.

C A extinção do contrato administrativo por ato unilateral da administração pública e a extinção consensual desse instrumento deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

D A decretação de falência do contratado é motivo inidôneo que enseja a extinção do contrato administrativo.

E A extinção do contrato administrativo decorrente de culpa exclusiva da administração dá ao contratado direito ao ressarcimento dos prejuízos que comprovadamente houver sofrido, não alcançado o pagamento de custos com a desmobilização.

Assinale a alternativa CORRETA.

Alternativas

A Uma das características do contrato administrativo reside em sua imutabilidade.

B A presença da Administração Pública como contratante caracteriza o contrato administrativo que, em consequência, será regido pelo direito público.

C Os contratos administrativos são dotados de cláusulas exorbitantes.

D A nulidade de contratos administrativos somente poderá ser declarada por órgão jurisdicional.

E Denomina-se fato do príncipe toda ação ou omissão da Administração, relacionada com o contrato, que impeça ou retarde a sua execução.